

1503211-41.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... na realidade, seria destinado a tráfico ilícito. Isto porque, a prova oral, consubstanciada principalmente nos depoimentos dos policiais militares, revelou que na ocasião dos fatos a equipe de força tática recebeu informação privilegiada dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o qual estaria vendendo drogas para levantar dinheiro para fugir de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Jardim São Silvestre, Ourinhos - SP - cep 19902-610

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503211-41.2022.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO LUIS DE MATOS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Aos 01 de dezembro de 2022, às 13:30horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ré(u)(s) em epígrafe, em consonância com o artigo 1º, § 1º, do Provimento CSM n.º 2.651/2022, observadas as disposições do Comunicado CG n.º 284/2020, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado(a), realizada por meio virtual. Apregoadas as partes, participaram da videoconferência o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Marcos da Silva Brandini, o(a)(s) defensor(a)(es) constituído(a)(s), Dr(a). Amanda Cristina Rossigalli OAB 403632/SP, o(a)(s) ré(u)(s) Juliano Luis de Matos e a(s) testemunha(s) Robson Fabrício Quintana de Faria, Vinicius de Moraes Godoi, Janaina Cristina de Matos, Maria Alice de Matos Souza e Maiara Cristina de Oliveira. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado pela inversão processual, com o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s) ao final da instrução, seguindo inteligência do HC 127900 - STF, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, Processo Eletrônico DJe-161 Divulg 02-08-2016 Public 03-08-2016, por ser medida de garantia à ampla defesa do(a)(s) ré(u)(s). Ato contínuo, foi(ram) ouvida(s) duas testemunha(s) da acusação. Dada a palavra ao(à) Promotor(a)

de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foi dito que desistia da oitiva da testemunha Maiara Cristina de Oliveira, o que foi homologado. A seguir, foi(ram) ouvida(s) duas testemunha(s) de defesa. Após, foi colhido o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s). Declarada encerrada a instrução processual pelo(a) MM. Juiz(a), foi dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que requereu a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a)(s) defensor(a)(es) do(a)(s) ré(u)(s) foi requerida a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Vistos. JULIANO LUIS DE MATOS, qualificado a fls. 07, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque segundo a denúncia na tarde de 22 de agosto de 2022, por volta das 18h20, na Rua Joaquim Floriano da Silva, nº 940, Vila São Luiz, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, guardava e tinha em depósito, para fins de consumo e comércio, 40,19 g de cocaína e 5,68 g de Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha. O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia, com rol testemunhal (fls. 144/147). A denúncia foi recebida em 06 de outubro de 2022 pela decisão proferida às fls. 167/171, após o que o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas defensivas e tomado o interrogatório do réu, seguindo-se pelos debates orais, nos quais o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por seu turno, alegou preliminares e, no mérito, alegou não haver provas para subsidiar a condenação. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação. Em sede preliminar a Defesa arguiu preliminar de nulidade processual decorrente do cerceamento do direito da defesa de acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante. A preliminar não merece acolhimento haja vista que eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. Ademais, como se sabe, para que ocorra o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual é necessário que seja demonstrado a existência de prejuízo ao acusado, a luz do artigo 563 do CPP (pas de nullité sans grief), dano que não restou evidenciado na hipótese. Por tais fundamentos rejeito a preliminar. Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de nulidade do flagrante decorrência da ilegalidade do ingresso policial à residência do acusado, onde os entorpecentes foram localizados e apreendidos. Isto porque as provas colhidas na audiência de hoje mostraram que na oportunidade dos fatos a equipe policial recebeu informação privilegiada no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas, o qual estaria na posse de grande quantidade de maconha e realizando a venda das drogas para juntar certa quantia que iria utilizar para fugir de uma recente condenação criminal. Diante da informação recebida a equipe de Força Tática decidiu averiguar a informação e iniciou patrulhamento com vistas a localizar o réu, oportunidade em que se deslocaram até as proximidades da casa dele, onde o encontraram conversando com um terceiro, salientando que ele, ao notar a presença da viatura policial no local, correu em direção a sua residência, sendo perseguido e alcançado quando estava no corredor do quintal, onde a equipe policial, em buscas pelo local, acabou localizando uma mochila que continha os entorpecentes, a qual o réu acabou confessando que lhe pertencia. Percebe-se, diante deste contexto, que a fuga do réu ao notar a aproximação da viatura policial, aliada as informações privilegiadas recebidas pelos policiais justificaram o ingresso na residência do acusado, posto que os elementos mostravam fundadas razões sobre a situação flagrancial por crime permanente na qual incurso o abordado, revestindo de legalidade a ação policial. Ademais, excerto extraído do Recurso Extraordinário nº 603.616/R0) pondera: "Nada impede, contudo, que essas informações venham a dar base a pesquisas e, uma vez robustecidas por outros elementos, embasem a busca. Logo, a tese é coerente com a jurisprudência acerca do lastro mínimo para medidas invasivas. A solução

preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário. O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja, a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois. A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos. Há também casos que apresentarão complexidades que ultrapassarão os limites do tema aqui apreciado. Por exemplo, numa investigação sigilosa, pode surgir a notícia do crime permanente dentro de residência. No entanto, dar acesso ao dono da casa a todos os dados da investigação pode comprometer o restante das pesquisas. Em tese, poder-se-ia realizar investigação independente, documentando indícios mínimos para a busca e retendo o restante da prova. Os limites dessa prática, no entanto, não são aqui debatidos. Também é comum que, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, revelem-se situações de flagrante delito não previstas no objeto inicial. Numa busca por drogas, por exemplo, podem-se encontrar armas de uso proibido. Em princípio, o ingresso forçado está autorizado, pelo que não se cogita de vulneração da garantia da inviolabilidade de domicílio. No entanto, novamente, os limites da prática não são aqui debatidos. Tampouco se pretende aferir a validade de mandados de busca e apreensão coletivos. Esse expediente, que vem sendo usado em operações em favelas e comunidades conflagradas, testa os limites da garantia contra a inviolabilidade da casa de formas que não comportariam análise no presente tema. Outra questão não apreciada é a validade do consentimento do morador. As hipóteses concretas podem revelar desdobramentos complexos, seja quanto à prova do consentimento, seja quanto a sua validade e suficiência. A Suprema Corte dos Estados Unidos vê com desconfiança o consentimento do morador obtido pelo agente estatal “sob autoridade governamental” (under government authority) ou “sob as cores do uniforme” (under color of office) – respectivamente, casos *Amos v. United States*, 255 U.S. 313 (1921) e caso *Johnson v. United States* 333 U.S. 10 (1948). Já houve algum debate sobre o assunto no HC 79.512, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 16.12.1999. O tema em julgamento, no entanto, não se presta a resolver a questão. Enfim, há uma infinidade de complicadores que merecem avaliação em separado. Será a casuística que impulsionará o desenvolvimento de jurisprudência para enfrentar os diferentes temas”. Na esteira dessa irretocável e refletida fundamentação, necessário se ater ao que de concreto consta no caso sub judice, na qual se constata que o ingresso policial decorreu do conjunto de elementos fáticos que circundam a abordagem, os quais revelaram a situação de flagrante delito, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade. Com esteio nos fundamentos colimados, rejeito a preliminar, passando ao exame meritório. Cuida-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática do delito de tráfico, a qual merece procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória. Isso porque, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12; auto de exibição

e apreensão de fls. 15/16, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 20/22 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 127/131. A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto. Em seu interrogatório policial, o réu Juliano Luis de Matos afirmou ter sido abordado dentro de sua casa, onde se encontrava deitado, confirmando estar se desfazendo da cafeína, a qual havia comprado para o seu consumo, e estava no interior da mochila localizada pelos policiais. Confirmou também a existência de uma balança de precisão na referida mochila, objeto este que sua irmã iria jogar fora, então pegou para si e utilizava para pesar as drogas que comprava para o consumo pessoal. Salientou que comprou cafeína e não cocaína. Admitiu, ainda, a propriedade da porção de maconha apreendida, sustentando a destinação pessoal, a qual foi entregue aos policiais por sua companheira. Negou a

prática da traficância. Em juízo, o acusado manteve a versão negativa, admitindo a propriedade dos entorpecentes, porém negando a prática da traficância. Salientou que o ingresso dos policiais em sua residência foi ilegal pois desacompanhado de autorização judicial. Disse que estava dentro de sua casa quando ficou sabendo que os policiais estavam acordando seu cunhado Wesley na rua, ocasião em que ficou com medo que os policiais pudessem estar na posse de um mandado de prisão contra ele e decidiu se desfazer de uma pequena porção de cocaína que possuía para misturar com cafeína para consumir antes de ir treinar na academia. Do mesmo modo, decidiu se desfazer de uma balança de precisão que estava guardada em sua casa, mas que era usada por sua irmã para produzir bolo. Disse que colocou tanto a droga com a cafeína como também a balança de precisão dentro de uma mochila, a qual jogou no imóvel vizinho, após o que começou a recolher a roupa do varal, a fim de dispersar a atenção dos policiais, os quais entraram no quintal sem autorização e começaram a perguntar sobre as drogas, dizendo que tinham informações de que o interrogando estava na posse de cinco quilos de maconha para tráfico. Informou que começou a questionar os militares se eles tinham autorização para entrar na casa, o que foi negado, após o que, por pressão dos militares, acabou confessando que tinha uma porção de maconha dentro de sua casa, tendo a esposa dele localizado a droga e entregue aos policiais. Na sequência informou que os policiais continuaram pressionando, sob ameaça de que iriam prender familiares do réu se ele não entregasse a eles os entorpecentes, razão pela qual acabou confessando aos militares que havia dispensado a mochila contendo a droga, objeto este que os policiais somente vieram a encontrar depois que a advogada do réu já estava na casa, porém ressaltou que já havia informado aos policiais sobre a existência da mochila contendo a cocaína. Afirmou que após a localização dos entorpecentes os policiais entraram em um acordo com o interrogando, a fim de garantir que o interrogando afirmasse que o ingresso na residência ocorreu de forma legítima. Por fim, admitiu a posse da cocaína, porém negou a destinação mercantil. Por sua vez, os policiais militares Robson Fabrício Quintana de Faria e Vinícius de Moraes Godoi, prestaram declarações uníssonas, narrando em solo policial que policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Vila São Luiz. Neste momento, foram abordados por um morador, que preferiu não se identificar por medo de represálias, o qual lhes informou que o réu estaria na posse de quantidade de maconha e cocaína, entorpecentes estes destinados a comercialização. Além disso, o delator ainda informou que o réu estaria traficando para levantar quantia e fugir, pois havia recebido recente condenação de dezesseis anos de prisão por crime de tentativa de homicídio. Disseram que a informação se mostrava sólida, haja vista que a guarnição policial tinha conhecimento acerca da referida condenação do acusado, que já era conhecido nos meios policiais por prática anterior de crime dessa natureza. Diante desse contexto, seguiram em diligência até a rua onde o réu reside e de frente ao endereço visualizaram duas pessoas conversando, sendo que uma delas correu para interior do imóvel ao avistar a viatura, levantando fundadas suspeitas de ilicitude, razão por que o réu foi acompanhado e revistado. Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém o acusado acabou admitindo a existência de maconha no interior de sua residência, a qual foi apresentada à equipe policial espontaneamente pela companheira do réu, efetivando-se o contexto flagrancial. Em seguida, verificado o telhado vizinho, foi encontrada uma mochila, dentro da qual havia cocaína e uma balança de precisão, tendo o réu admitido a propriedade, assim como informalmente admitiu aos policiais a finalidade mercantil, relatando que estaria realizando a venda para aquisição de enxoval para a filha que irá nascer nos próximos dias. Ocorreu, ainda, a apreensão de quantia em notas variadas. Em juízo, os policiais repetiram a narrativa inicial, salientando que a equipe de Força Tática estava realizando patrulhamento pelo Bairro Vila São Luiz, oportunidade em que foram informados por moradores que o Juliano, conhecido pela alcunha de "Baiano" estaria na prática do tráfico de drogas e que ele teria adquirido cinco quilos de maconha para vender e fugir da cidade, em razão de uma recente condenação pela prática do crime de tentativa de homicídio, no qual foi condenado a pena de dezesseis anos. Diante da informação intensificaram patrulhamento pelas proximidades da casa do réu, ocasião em que avistaram Juliano

na rua Joaquim Floriano da Silva mantendo contato com um outro indivíduo, tendo ele, ao notar a presença da viatura policial, corrido em direção a sua casa, porém foi perseguido e alcançado quando estava em um corredor do quintal que dá acesso a três casas construídas em um mesmo terreno. Na oportunidade ele foi questionado sobre o motivo da fuga, tendo dito que havia fugido por medo de haver um mandado de prisão expedido em decorrência da condenação por tentativa de homicídio. Na sequência, após consulta ao sistema Prodesp, constatou-se que não havia qualquer mandado de prisão expedido em desfavor do réu, o que foi informado a ele, porém notou-se que mesmo assim ele continuou demonstrado nervosismo, o que fortaleceu a suspeita da prática de ilícito e motivou uma busca minuciosa no local, a qual resultou na localização de uma mochila que continha cocaína, uma balança de precisão e papel filme. Ato contínuo o réu admitiu a propriedade da mochila que continha o entorpecente, bem como confessou a prática da traficância, salientando que venderia cada porção de cocaína pelo valor de R\$150,00. Finalmente informaram que o réu confessou a existência de uma porção de maconha dentro de sua residência, a qual foi apresentada a equipe policial pela esposa dele, bem como informou que possuía a quantia de R\$1070,00, fruto da venda de drogas. A companheira do réu, Maiara Cristina de Oliveira disse que ela e o réu estavam deitados dentro de casa, quando a tia dele viu a polícia abordar o marido de sua cunhada na calçada do imóvel e foi avisá-los. Neste momento, o réu saiu do quarto para recolher roupas, tendo os policiais ingressado na área e começaram a revistar o fundo e lateral da casa, acionando outra viatura. Disse que o réu foi abordado na área de serviço, onde ele estava recolhendo a roupa e os policiais começaram a perguntar se tinha drogas e chamaram outra viatura para pegar uma escada. Neste momento, o réu pediu para a depoente pegar a maconha dele, que era destinada ao consumo pessoal e entregar os policiais. Então, foi até o guarda-roupa, sem ter sido acompanhada por nenhum policial, pegou a maconha e a caixa de seda e entregou para o policial. Posteriormente, perguntaram novamente se tinha mais drogas e falaram que não iria prendê-lo. Afirmou não ter visto a mochila que foi encontrada pelos policiais, no entanto relatou que os policiais pegaram uma escada e subiram no muro para procurar e ouviu eles falando que tinha uma mochila, a qual foi revistada e tinha cocaína em seu interior. Esclarecendo que era um pó branco, que achava que era cafeína e uma balança. Disse que o réu admitiu a propriedade da mochila e o policial perguntou se pretendia vender, tendo o réu respondido que ia vender um pouco para comprar o enxoval para filha. Disse que desconhecia aquela mochila. Depois disso, os policiais entraram na residência por causa do dinheiro, o qual buscou e entregou ao policial. Confirmou que o acusado disse aos policiais que poderiam entrar e revistar a casa porque não havia nada ali e realmente não encontraram nada nas buscas na residência. Finalmente, as testemunhas defensivas Maria Alice de Matos Souza e Janaina Cristina de Matos informaram que estavam no local dos fatos quando a polícia militar invadiu a casa do réu, o qual estava dentro de sua residência quando os policiais entraram no imóvel sem qualquer razão e passaram a acusá-lo da prática do tráfico de drogas. Estes são, em síntese, os elementos probatórios reunidos nos autos. Nota-se que, muito embora o réu tenha negado a prática da traficância, acabou confessando a propriedade da cocaína e maconha apreendida na ocasião, as quais, no entanto, afirmou serem destinadas ao seu próprio consumo. Não obstante, as circunstâncias que envolveram a abordagem do réu revelam que o entorpecente, na realidade, seria destinado a tráfico ilícito. Isto porque, a prova oral, consubstanciada principalmente nos depoimentos dos policiais militares, revelou que na ocasião dos fatos a equipe de força tática recebeu informação privilegiada dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o qual estaria vendendo drogas para levantar dinheiro para fugir de uma condenação criminal. Diante da informação recebida, os policiais decidiram intensificar patrulhamento nas imediações da residência do réu, ocasião em que o encontraram conversando com um terceiro, porém notaram que ele, ao perceber a aproximação da viatura policial, saiu correndo em direção de sua residência, o que fortaleceu a suspeita da prática de ilícito e ensejou o seu acompanhamento até o interior do imóvel, tendo o réu sido alcançado em um corredor que dá acesso a casa do réu e outras duas residências. No local os policiais acabaram localizando uma mochila

dentro da qual foram encontradas drogas, uma balança de precisão e plástico filme, tendo o réu admitido informalmente aos policiais que estava traficando, inclusive informou que possuía a quantia de R\$ 1.070,00 dentro de sua casa, que seria fruto da venda de drogas. Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas. Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos. Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello) Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante: "Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018). Oportuno, ainda, ressaltar que a versão do réu, no sentido de que estava dentro de sua casa quando os policiais adentraram o imóvel de forma irregular, além de fantasiosa, não foi confirmada por elementos de prova sólidos, uma vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas por ele devem ser recebidos com ressalva, em razão do grau de parentesco que possuem com o réu. Diante deste contexto probatório, não há como se privilegiar a frágil versão defensiva em detrimento da acusatória, a qual, como visto, restou sobejamente demonstrada através das declarações dos policiais militares e demais circunstâncias que envolveram a prisão do réu. Portanto restando suficientemente que o ingresso policial no imóvel ocorreu de forma legítima e que a mochila dentro da qual foi encontrada a droga pertencia ao réu, resta analisar sua destinação, isto é, se seria destinada ao tráfico, como sustentou a acusação, ou se seria destinada ao consumo do próprio acusado, conforme alegou o réu em sua defesa técnica. Nesse aspecto é importante ressaltar que para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o acusado seja flagrado comercializando drogas, bastando a prática de quaisquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL FIM DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76, não se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas estabelecidas no dispositivo. 2. De outro lado, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito descrito no artigo 16 da Lei de Tóxicos somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso própria da substância, elementar subjetivo especial do tipo. 3. Recurso especial conhecido e provido (REsp. 812.950/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008). No caso, o réu foi flagrado guardando e mantendo em sua

posse a quantia de 40,19 gramas de cocaína e 5,68 gramas de maconha, o que, embora não se mostre exorbitante, constitui forte indício da traficância, posto que o cotidiano forense tem mostrado que cada porção de cocaína pesa em média 0,25 gramas e de maconha, 0,6 gramas. Além disso, foi encontrado dentro da mochila que guardava o entorpecente uma balança de precisão e plástico filme, objetos estes que usualmente são utilizados na preparação da droga para venda no varejo. Soma-se a este indício que, além do entorpecente, foi apreendida a quantia de R\$ 1.070,00 (um mil e setenta reais) em dinheiro, cuja origem deste valor não restou suficientemente esclarecida, sendo possível concluir, diante do contexto dos autos, que o montante restante foi obtido através da venda de drogas. Todas estas circunstâncias da prisão em flagrante, aliado ao conjunto probatório consubstanciado principalmente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência e do teor das declarações da testemunha civil ouvida, comprovam, de forma inequívoca, que o acusado se dedicava à nefasta mercancia de drogas. Portanto, presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do réu deve ser condenado e submetido ao cumprimento da lei penal, por ser medida de justiça. Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu não possui registros criminais, que consubstanciem maus antecedentes (fls. 120/122) e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, cuja natureza da substância apreendida (cocaína), será sopesada na derradeira fase, evitando-se inadmissível bis in idem. Nesses termos, fixo a pena base acima em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Finalmente, na última fase, considerando a primariedade técnica do denunciado e a ausência de indícios nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo possível a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, no entanto, a redução deve ser modulada de acordo com a natureza das drogas apreendidas. Neste sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. (HC 440.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) destaquei. Destarte, diante da apreensão de cocaína, na forma do subproduto cocaína, de alto poder viciante e nocivo à saúde humana, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço) alcançando o montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena esta que converto em definitiva por não encontrar circunstância modificadora aplicável. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime. Em relação à definição do regime inicial para o cumprimento da pena corporal, anoto que o tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a solidificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ficando afastada a incidência das disposições da Lei n.º 8.072/90. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu em sede de repercussão geral que "é

inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal"(RE 1052700, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgamento em 2.11.2017, DJe de 1.2.2018, Tema 972). Importante ressaltar, outrossim, a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ no julgamento do HC 596.603-SP, que proibiu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena para o crime de tráfico na modalidade privilegiada. Seguindo tais orientações e atenta aos princípios da individualização e da suficiência (artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal), verifico a natureza do entorpecente traficado afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu, razão pela qual fixo ao réu o regime intermediário - semiaberto. Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Nesses termos, observa-se que o réu permanece encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra suficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 16% da pena, conforme art. 112, I, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial SEMIABERTO. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JULIANO LUIS DE MATOS, qualificado a fls. 07, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. No tocante aos valores apreendidos no feito, não tendo sido comprovado a origem lícita, conclui-se diante do contexto probatório que foram obtidos através do tráfico ilícito de drogas, o que determina o perdimento na forma da lei. Assim, declaro a perda dos valores em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06. O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a sua responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado. Ademais, muito embora seja tecnicamente primário, o acusado ostenta condenação por crime de tentativa de homicídio sem trânsito em julgado, como se vê às fls.120/122, demonstrativo de sua periculosidade. Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis, no entanto deve ser encaminhado para unidade carcerária compatível com o regime. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudescer as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal. Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu: "Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas - declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum - decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência - Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem



denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei. Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhe, expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim. De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Publicada em audiência. Lida a sentença ao(a)(s) ré(u)(s), este(a)(s) assistido(a)(s) por seu/sua(s) defensor(a)(s) declarou que deseja recorrer do decreto condenatório. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Considerando a manifestação do(a)(s) ré(u)(s) Juliano Luis de Matos recebo o recurso, processando-se-o. Sai(em) o(a)(s) doutor(a)(es) defensor(a)(es) intimado(a)(s) de que no dia 02 de dezembro de 2022 se inicia o prazo para a apresentação das razões do recurso". Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes no presente termo, por se tratar de audiência virtual ou semi presencial. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as declarações e manifestações foram captadas através do aplicativo Microsoft Teams e carregadas ao sistema SAJ/PG5, nos termos do Comunicado Conjunto n.º 1.350/2020 do TJSP, disponibilizadas para consulta às partes através do portal eletrônico e-SAJ. NADA MAIS. Eu, (Francisco Airton Notari), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA